

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3901/2532

บริษัท เงินทุน มหาทุน จำกัด  
นาง ทอง หยิบ ขำ นิ ล

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 65, มาตรา 161, มาตรา 167, มาตรา 229, มาตรา 249

จำเลยขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยมาแล้ว 1 ครั้ง อ้างว่าทนายจำเลยป่วย ศาลอนุญาตโดยกำชับให้จำเลยเตรียมพยานมาสืบให้พร้อม ถ้าพยานปากใดไม่มาถือว่าไม่ตั้งใจสืบ ครั้นถึงวันนัดทนายจำเลยมอบฉันทะให้ ป. มายื่นคำร้องว่าทนายจำเลยขอถอนตัวจากการเป็นทนายให้จำเลย และขอเลื่อนคดีไปเพื่อให้จำเลยหาทนายใหม่ โดยไม่ปรากฏว่าการขอถอนตัวจากการเป็นทนายได้แจ้งให้ตัวจำเลยทราบหรือหาตัวจำเลยไม่พบ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ทนายถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลย จึงชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 65 เมื่อจำเลยยังมีทนายอยู่ จึงไม่มีเหตุที่จะขอเลื่อนคดีเพื่อให้จำเลยหาทนายใหม่ทั้งการที่ศาลชั้นต้นได้กำชับในนัดก่อนแล้วว่า หากพยานปากใดไม่มาศาล ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยาน เมื่อไม่มีพยานจำเลยมาศาลเลยศาลชั้นต้นจึงดสืบพยานจำเลยเสียได้ ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาว่า จำเลยไม่ได้ทำสัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดจากโจทก์ 200,000 บาท และจำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ในทุนทรัพย์ตามจำนวนเงินในเช็คและดอกเบี้ยรวม 270,363 บาท เท่านั้น ดังนั้นปัญหาว่าจำเลยได้กู้เงินและรับเงิน 400,000 บาทไปจากโจทก์หรือไม่ จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่า จำเลยได้กู้และรับเงิน 400,000 บาทจากโจทก์ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์โดยชอบ จำเลยจะยกขึ้นฎีกา

ต่อมาไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229หมายความว่ารวมถึงค่าทนายความด้วย ซึ่งผู้อุทธรณ์ต้องนำมาวางศาลพร้อม อุทธรณ์.

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นจำนวน 600,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 253,595 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 853,595 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ของต้นเงิน 400,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์แล้วเสร็จและ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ หากจำเลยไม่ชำระก็ให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองขาย ทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลย ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์ไม่ได้บอก กล่าวบังคับจำนองแก่จำเลย โจทก์คิดดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 600,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 20 ต่อปีของเงินจำนวน 400,000 บาทนับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน ตามเช็คแต่ละฉบับ(ฉบับละ 100,000 บาท) นับแต่วันที่ 4 และ 7 เมษายน 2526เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนองออก

ขายทอดตลาดชำระหนี้แทน กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโดยกำหนดค่า  
ทนายความ 2,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท  
แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นไม่ให้จำเลยเลื่อนคดีและงด  
สืบพยานจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เกี่ยวกับคดีนี้ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยนัด  
แรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ครั้นถึงกำหนดทนายจำเลยมอบฉันทะให้นางประไพ  
พิชัยกุลมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อน  
ไปสืบพยานจำเลยวันที่ 3 มิถุนายน 2528 โดยกำชับให้จำเลยเตรียมพยานมาสืบให้  
พร้อม ถ้าพยานปากใดไม่มาถือว่าไม่ตั้งใจสืบครั้นถึงวันนัดทนายจำเลยมอบฉันทะให้  
นางประไพมายื่นคำร้องว่าทนายจำเลยขอถอนตัวจากการเป็นทนายให้จำเลยและขอ  
เลื่อนคดีไปเพื่อให้จำเลยหาทนายใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่ปรากฏว่าการขอถอน  
ตัวจากการเป็นทนายได้แจ้งให้ตัวจำเลยทราบหรือหาตัวจำเลยไม่พบ จึงไม่อนุญาต  
ให้ทนายถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยและไม่มีเหตุที่จะเลื่อนคดีเพื่อให้จำเลยหา  
ทนายใหม่ ประกอบทั้งศาลได้กำชับจำเลยให้เตรียมพยานมาให้พร้อมในนัดนี้เพราะ  
ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีมาครั้งหนึ่งแล้ว จึงให้ยกคำร้องขอเลื่อนคดีและถือว่าจำเลย  
ไม่มีพยานมาสืบและให้งดสืบพยานจำเลยเสีย เช่นนี้ ศาลฎีกาพิเคราะห์เห็นว่า การที่  
ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยขอถอนตัวจากการเป็นทนายให้จำเลยชอบด้วย  
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 65 แล้ว และเมื่อ  
ทนายจำเลยยังคงเป็นทนายให้จำเลยอยู่ก็ไม่มีเหตุที่จะขอเลื่อนคดีเพื่อให้จำเลยหา

ทนายใหม่ ทั้งศาลชั้นต้นก็ได้กำชับไว้ในนัดก่อนแล้วว่าหากพยานปากใดไม่มาศาล ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานจำเลย ดังนั้นเมื่อไม่มีพยานจำเลยมาศาลเลย ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะสั่งงดสืบพยานจำเลยเสียได้ คำสั่งศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า คำฟ้องของโจทก์มีข้อความสับสนขัดแย้งกันกล่าวคือ โจทก์ไม่ได้บรรยายในคำฟ้องว่าหนี้เงินอันเกิดจากการที่จำเลยนำเช็ค 2 ฉบับ จำนวนเงิน 200,000 บาท ไปแลกเงินสดจากโจทก์เกี่ยวพันกับหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 400,000 บาทอย่างไร และที่โจทก์อ้างในคำฟ้องว่า วันที่ 9 มิถุนายน 2525 จำเลยขอขึ้นเงินจำนวนอีก 200,000 บาท รวมเป็น 600,000 บาทนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหนี้ตามสัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดเพียงใด ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุมนั้นปรากฏว่า จำเลยให้การถึงเหตุที่อ้างว่าคำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมแต่เพียงว่าโจทก์จะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ไหนดกับใคร เมื่อไรโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ชัดเจนและทั้งโจทก์ก็ไม่ได้บรรยายว่าได้จดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ อันเป็นคนละเหตุกับเหตุที่จำเลยฎีกา จึงถือไม่ได้ว่าฎีกาของจำเลยข้อนี้เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยฎีกาข้อนี้ให้ ส่วนที่ว่าโจทก์จะมีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น เห็นว่า โจทก์มีนายสม อางค์เย็นยิ่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของโจทก์มาเบิกความประกอบรายชื่อกรรมการของโจทก์ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 และโจทก์ได้มอบอำนาจให้พยานฟ้องคดีนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 จำเลยไม่มีพยานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น คดีจึงรับฟังได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยกู้และรับเงินกู้ไปจากโจทก์ รวมทั้งฟังว่าจำเลยได้นำเช็คจำนวน 2 ฉบับไปแลกเงินสดจากโจทก์เป็นข้อวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน จำเลยมีพยานหลักฐานที่จะนำสืบหักล้างนั้น ปรากฏว่าในชั้นอุทธรณ์ จำเลย

อุทธรณ์เฉพาะปัญหาว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดจากโจทก์จำนวน 200,000 บาทและจำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ในทุนทรัพย์ตามจำนวนเงินในเช็คและดอกเบี้ยรวม 270,363 บาท เท่านั้น ดังนั้น ปัญหาว่าจำเลยได้กู้เงินและรับเงิน 400,000 บาท ไปจากโจทก์หรือไม่ จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าจำเลยได้กู้และรับเงิน 400,000 บาท จากโจทก์ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์โดยชอบ จำเลยจะยกขึ้นฎีกาต่อมาไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 คงมีปัญหาวินิจฉัยว่าจำเลยได้นำเช็คจำนวน 2 ฉบับ สั่งจ่ายเงินฉบับละ 100,000 บาทไปแลกเงินสดจากโจทก์หรือไม่ โจทก์มีนายสมอ้างค์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของโจทก์มาเบิกความประกอบเอกสารได้ความว่า วันที่ 9มิถุนายน 2525 จำเลยทำสัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดจากโจทก์ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีตามเอกสารหมาย จ.5 จำเลยนำเช็ค 2 ฉบับ สั่งจ่ายเงินฉบับละ 100,000 บาทมาแลกเงินสดจากโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.6 โดยจำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 8872 ตำบลสี่แยกมหานาค (ดุสิต) อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร ไว้แก่โจทก์เป็นประกันหนี้ตามเอกสารหมาย จ.12 จ.13 เมื่อเช็คทั้งสองฉบับถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ให้เหตุผลว่า โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย ตามเอกสารหมาย จ.7 ถึง จ.10จำเลยไม่มีพยานนำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงฟังได้ตั้งโจทก์นำสืบว่า จำเลยนำเช็ค 2 ฉบับไปแลกเงินสดจากโจทก์ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาข้อต่อมาว่า การบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยตามฎมิลำเนาที่จำเลยได้ให้โจทก์ไว้ และเป็นฎมิลำเนาที่ใช้ในการติดต่อระหว่างโจทก์และจำเลยเสมอมา ทั้งคำฟ้องของโจทก์ก็ระบุฎมิลำเนาตามที่

โจทก์ส่งคำบอกกล่าวบังคับจำนองไป ส่วนคำให้การของจำเลยก็ระบุว่า จำเลยอยู่บ้านเลขที่ 160/16 ถนนกรุงเกษม ซอยตลาดผดุงเกษม แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตรงตามฟ้องของโจทก์ ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่จริงตามคำฟ้อง และคำบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์ หากจำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่จริง จำเลยคงไม่ได้รับสำเนาคำฟ้องของโจทก์และยื่นคำให้การแก้คดีภายในกำหนด ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ส่งคำบอกกล่าวบังคับจำนองให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 มิได้บัญญัติไว้เป็นเด็ดขาดว่า ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษามาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ ทั้งเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็มิได้บัญญัติว่าหมายความว่าถึงเงินค่าทนายความด้วย ศาลชั้นต้นชอบที่จะรับอุทธรณ์ของจำเลยนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์นั้นด้วย ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์กับค่าทนายความมาวางศาลก่อนโดยให้จำเลยชำระภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่รับอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย เพราะค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้หมายความว่ารวมถึงค่าทนายความที่ศาลสั่งด้วย ซึ่งจำเลยต้องนำมาวางพร้อมอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ที่จำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาเต็มตามทุนทรัพย์ที่ฎีกานั้น เมื่อศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาบางข้อของจำเลย จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้แก่จำเลยบางส่วน โดยคงให้เหลือไว้ตามจำนวนทุนทรัพย์เท่าที่ศาลฎีการับวินิจฉัย

พิพากษายืน คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้แก่จำเลยโดยคงให้เหลือไว้เท่าจำนวนทุน  
ทรัพย์ 270,363 บาท ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา1,000 บาท แทนโจทก์.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |